

1500028-35.2020.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2002152/2020 - DEL.POL.SALTO, 9319025 - DEL.POL.SALTO, 16/20/512 - DEL.POL.SALTO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

2ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500028-35.2020.8.26.0569 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500028-35.2020.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2002152/2020 - DEL.POL.SALTO, 9319025 - DEL.POL.SALTO, 16/20/512 - DEL.POL.SALTO, 2002152 - DEL.POL.SALTO, 16/20/512 - DEL.POL.SALTO, 2002152 - DEL.POL.SALTO, 16/20/512 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE DE OLIVEIRA VIANA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Vistos.

HENRIQUE DE OLIVEIRA VIANA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III, ambos da Lei Federal nº 11.343/2006, porque, no dia 3 de janeiro de 2020, por volta de 22h43min, na rua Bolívia, altura do nº 583, Jardim Planalto, nas imediações de recinto público onde se realizam atividades e diversões de natureza esportiva e de lazer, nesta cidade e comarca de Salto, trazia consigo e guardava, para venda e entrega a consumo a terceiros, ainda que gratuitamente, 51 (cinquenta e uma) porções de "cocaína", com massa bruta de 73,9g (setenta e três gramas e noventa centigramas), e 70 (setenta) porções de "cocaína", em sua forma petrificada popularmente conhecida como "crack", com massa bruta de 17,4g (dezessete gramas e quarenta centigramas), todas acondicionadas em

invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Durante a audiência de custódia, o réu foi beneficiado com liberdade provisória mediante condições (fls. 23/26) e, posteriormente, não foi localizado para notificação (fls. 89), razão pela qual se decretou sua prisão preventiva a pedido do Ministério Público (fls. 93/94 e 96/97). A nova prisão se deu em 2 de agosto de 2021 (fls. 123, 126/129 e 139/140).

A denúncia foi oferecida em 12 de maio de 2020 (fls. 73/77). O réu foi notificado (fls. 185) e apresentou defesa prévia (fls. 189/192). A denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2021 (fls. 199/201) e o réu foi citado (fls. 240/241).

Durante a instrução, foram ouvidas 03 testemunhas arroladas em comum pela Acusação e Defesa, homologou-se a desistência de oitiva da testemunha Felipe de Jesus Lago, indeferiu-se o pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica, e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 249/252).

Em memoriais, o Dr. Promotor de Justiça, pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, reconhecimento da causa de aumento atinente ao local da prática do crime, entendendo não ser possível a benesse do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. Ao final, requereu a fixação do regime fechado, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sem substituição por penas restritivas de direitos (fls. 259/268). A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação penal, por insuficiência probatória, com a consequente absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o artigo 28, da lei em comento ou, em caso de procedência, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, regime aberto para início do seu cumprimento, além do direito de recorrer em liberdade (fls. 270/272).

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade dos crimes ficou incontroversa, conforme auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 02/04), auto de exibição, apreensão e constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 05/07), laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 55/58 e 59/62), além da prova oral, colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria do crime ficou confirmada.

O réu, em sede policial, negou o crime, afirmando que a droga encontrada não era sua (fls. 13). Em juízo, tornou a negar o tráfico. Disse que estava no local e, ao sair para comprar cigarros, "bateu" de frente com a viatura e recebeu ordem de parada. O Felipe ia passando, já tinha passagem e, talvez por isso possa ter dito que a droga era do réu. Acrescentou que não conhecia Felipe, pois havia chegado havia pouco tempo de Sergipe, onde trabalhava como pedreiro. Disse que já havia visto os guardas que o prenderam, mas não os conhecia e nem tinha nada contra eles (fls. 252).

Diego Guiaro de Moraes, guarda municipal, disse que estavam em patrulhamento pela rua Finlândia, que fica perto de uma praça com campo de futebol e, chegando lá, avistaram dois indivíduos, que, ao verem os guardas, voltaram para o meio da praça, tentando evitar a abordagem. Mesmo assim, foram abordados e nada de ilícito foi localizado, apenas R\$15,00 com o réu. Porém, os GCMs Eduardo e Robson disseram ter visto, ao desembarcarem da viatura, que o réu retirou algo de sua blusa e jogou ao solo. Acrescentou que o objeto dispensado foi encontrado e se tratava de um saquinho que continha 51 pinos de cocaína e 70 porções de crack. Ao ser questionado, o réu permaneceu calado, enquanto o menor disse ter sido contratado para ficar como olheiro, pelo réu, e confirmou o tráfico. Ambos, o réu e o menor, eram vistos com frequência no local (fls. 251).

Eduardo Henrique Aparecido de Sousa, guarda municipal, apresentou testemunho em perfeita consonância com o de seu colega de farda, destacando que ele foi um dos guardas que viu quando o réu dispensou ao solo o saquinho contendo os 51 pinos de cocaína e as 70 porções de crack (fls. 251).

Robson Silveira Barbosa, guarda municipal, apresentou testemunho em perfeita consonância com o de seus colegas de farda, destacando que ele também viu quando o

réu dispensou ao solo o saquinho contendo os 51 pinos de cocaína e as 70 porções de crack. Acrescentou que, em poder do réu, foi encontrado também um aparelho celular e afirmou que não conhecia o réu ou o adolescente (fls. 251).

Inicialmente, cumpre pontuar que a versão apresentada pelos réus mostrou-se isolada do restante do conjunto probatório, numa clara tentativa de descaracterizar a ocorrência do crime.

Os depoimentos dos guardas municipais foram seguros, coesos, harmônicos e cheios de detalhes, e foram todos confirmados ao longo da instrução, além do que, o simples fato de serem ouvidos como testemunhas, não retira de seus depoimentos o prestígio, o peso e a veracidade. Ademais, como bem argumentou o Dr. Promotor de Justiça, decidir em contrário seria desprestigiar, injustificadamente, o agente da Administração Pública.

Neste sentido a jurisprudência:

"Tráfico de entorpecente - Decisão condenatória baseada em depoimento de policial - Descrição segura, precisa e uniforme dos fatos - Inexistência de motivos que o invalidem - Presunção de idoneidade - Preliminar de cerceamento de defesa repelida" (RT 614/275).

No mesmo sentido:

"Quanto ao que disseram os guardas, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos

milicianos". (TJSP; Apelação Criminal1510160-57.2018.8.26.0526; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020). Ainda:

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e aos depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

No tocante à idoneidade dos depoimentos dos agentes policiais, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório, importante ressaltar que, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional e com a observância dos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos.

Revestem-se, portanto, de inquestionável eficácia probatória, não cabendo suas desqualificações pelo simples fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão criminosa.

Assim o pacífico entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

No mesmo sentido, o Colendo Supremo Tribunal Federal entende que:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se

harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus Nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97).

Portanto, seus depoimentos devem ser plenamente considerados, até porque inexiste qualquer indício nos autos de que pretenderiam, deliberadamente, prejudicar o acusado, sendo certo que este último alegou que não conhecia os guardas.

Assim, pela coesão e harmonia de todo o contexto probatório, ficou mais do que evidente a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, exatamente como mencionado na denúncia.

Não há como se aceitar qualquer pretensão desclassificatória, até porque nenhuma prova efetiva neste sentido foi trazida.

Por amor ao debate, consigno que o simples fato de se transportar, guardar ou trazer consigo a substância entorpecente já configura a conduta tipificada. Neste sentido, a jurisprudência que ora me permito transcrever:

"A ausência de prova quanto à comercialização da maconha não desconfigura o crime previsto no art. 12, da Lei n. 6368/76. Adquirir ou guardar a substância tóxica, bastam à sua tipificação, pois, nem sempre é necessária a finalidade comercial." (TJBA Bahia Forense 18/173)

"O fato de alguém, sem a necessária autorização, guardar, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, por si só tipifica o delito do art. 12 da Lei antitóxica, pouco importando seja o depósito mantido em nome próprio ou por conta de terceiro" (TJSC JC 28/546)

Segundo entendimento do C. STJ, "O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente" (HC 332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em 23/02/2016, DJE 15/03/2016.)

Também restou suficientemente demonstrada a causa de aumento constante da denúncia (art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006), já que o tráfico de drogas ocorreu nas dependências de uma área de lazer, onde se realizam atividades recreativas e esportivas (fls. 248).

Em suma, encerrada a instrução, ficou evidenciado à saciedade que o réu praticou o crime descrito na denúncia, estando incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III, ambos da Lei Federal nº 11.343/2006, porque, no dia 3 de janeiro de 2020, por volta de 22h43min, na rua Bolívia, altura do nº 583, Jardim Planalto, nas imediações de recinto público onde se realizam atividades e diversões de natureza esportiva e de lazer, nesta cidade e comarca de Salto, trazia consigo e guardava, para venda e entrega a consumo a terceiros, ainda que gratuitamente, 51 (cinquenta e uma) porções de "cocaína", com massa bruta de 73,9g (setenta e três gramas e noventa centigramas), e 70 (setenta) porções de "cocaína", em sua forma petrificada popularmente conhecida como "crack", com massa bruta de 17,4g (dezessete gramas e quarenta centigramas), todas acondicionadas em invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Portanto, ficou provada de forma incontestada a ocorrência dos delitos e a conduta do acusado, razão pela qual, passo a aplicar-lhe as sanções cabíveis, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Atenta às circunstâncias dos artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal, entendo que a quantidade de porções da droga apreendida (51 porções de cocaína e 70 porções de crack) supera o que habitualmente é apreendido em crimes desta natureza na comarca, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, o mesmo ocorrendo em relação à natureza dos entorpecentes, mormente em razão das 71 porções de crack, droga de indiscutível e devastador potencial lesivo. Assim, fixo a pena-base do acusado, pelo crime de tráfico de entorpecentes, acima do mínimo legal, qual seja, em 05 anos e 06 meses de reclusão, além de 550 dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes.

Ante a presença da causa de aumento anteriormente mencionada (art. 40, incisos III, da Lei nº 11.343/2006), aumento a pena do acusado de 1/6 (um sexto), atingindo o patamar de 06 anos e 05 meses de reclusão e 641 dias-multa para o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006).

Acolho o pedido acusatório e, malgrado a primariedade do réu, deixo de lhe aplicar

o redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, por entender que restou plenamente configurada sua dedicação à atividade criminosa, já que não comprovou possuir emprego lícito ou demonstrou a origem do dinheiro com ele apreendido. Acrescento, nesse sentido, que embora o acusado tenha dito que havia chegado há poucos dias de Sergipe, a testemunha Diego Guiaro de Moraes disse que o réu era visto, com frequência, no local, ainda que nunca tivesse sido abordado anteriormente. Outrossim, a própria data de sua primeira prisão, e de sua segunda, deixaram um espaço de cerca de ano e meio, período em que foi visto pelos agentes policiais, desconstituindo a versão exculpatória que apresentou.

Torno a pena definitiva e fixo a unidade do dia-multa no mínimo previsto em lei. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação e CONDENO o réu HENRIQUE DE OLIVEIRA VIANA, qualificado nos autos, RG:7.097.183, CPF 348.019.938-00, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 06 anos e 05 meses de reclusão e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 641 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

O regime de cumprimento de pena deve ser o inicial fechado, não apenas em razão da gravidade do delito praticado (Súmulas 718 e 719 – STF; Súmula 440 – STJ), mas sobretudo pelo potencial lesivo da conduta do réu e das drogas apreendidas, que, por suas características e alcance, atingiria a centenas de usuários diretos, o que indica a necessidade de segregação absoluta, e também por entender que, neste caso específico, somente o regime fechado será suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado. Determino, ainda, que o denunciado não poderá recorrer desta sentença em liberdade, considerando que foi agraciado, em 04 de janeiro de 2020, com a liberdade provisória mediante condições (fls. 23/26) e, posteriormente, não foi localizado para notificação (fls. 89), razão pela qual se decretou sua prisão preventiva a pedido do Ministério Público (fls. 93/94 e 96/97), sendo certo que sua nova prisão se deu em 2 de agosto de 2021 (fls. 123, 126/129 e 139/140), ou seja, mais de um ano e meio após a data de sua soltura e quase um ano após não ter sido encontrado pela primeira vez. Assim, sua custódia de fez necessária para o encerramento da instrução penal, já que se mostra inalterado o panorama do momento em que foi determinada. Ademais, sabedor da condenação que agora pesa sobre ele, certamente tem mais motivos para tentar se furtar, vindo a frustrar eventual execução da pena. Pelas mesmas razões, não se mostra viável a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos.

Neste sentido, a jurisprudência oriunda de caso análogo desta Vara submetido a recurso:

"[...] Ademais, não se pode desprezar que a traficância é a mola propulsora da criminalidade que assola o país, uma vez que o usuário, na ânsia de sustentar seu vício, pratica toda sorte de delitos, abalando consequentemente toda a sociedade, circunstância que, por si só, justifica a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena. Nesse sentido entende o C. Superior Tribunal de Justiça: 'TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) Pela mesma razão, mostra-se possível a imposição de regime inicial fechado, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, uma vez que o magistrado possui a discricionariedade de agravar somente o aspecto qualitativo da pena, observado o art. 42 da Lei n. 11.343/06, que prepondera sobre o artigo 59 do Código Penal. Habeas Corpus não conhecido. (HC 300.274/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHÃO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 06/11/2015).' (EMBARGOS INFRINGENTES Nº 0000274-81.2015.8.26.0569/50000, Rel. Desembargador WILLIAN CAMPOS. 15ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 11/04/2019).

Observo não ser caso de aplicação da ordem exarada nos autos do HC nº 165.704-DF, rel. Min. Gilmar Mendes, conforme deliberação na sessão virtual de 20 a 27 de agosto p.p., item "a", onde foi determinada "reavaliação das prisões preventiva de pais e responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, de acordo com as diretrizes fixadas pela Segunda Turma", pois inexistem quaisquer elementos nos autos que comprovem que o réu se encontre na situação ali prevista. Considerando a redação do art. 387, parágrafo 2º, do CPP, forçoso reconhecer que

não se aplica ao presente caso, uma vez que não demonstrados os requisitos subjetivos para a progressão pleiteada, os quais deverão ser aferidos pelo juízo da execução. Neste sentido:

"Detração - Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade - Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 - Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP Entendimento. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença" (Apelação/Tráfico de Drogas 0023654- 12.2011.8.26.0590, Rel Grassi Neto, São Vicente, 8ª Câmara de Direito Criminal, p. 07.05.2015, j. 07.05.2015). Recomende-se o réu onde se encontra preso.

Decreto o perdimento dos valores e bens apreendidos nestes autos, em favor da União (artigo 63 da Lei 11.343/06) e, havendo laudo definitivo encartado aos autos, fica autorizada a destruição de eventual droga remanescente, observada a necessidade de contraprova, nos termos da lei.

Arbitro os honorários advocatícios do Procurador nomeado, no teto do Convênio.

Após, o trânsito em julgado expeça-se certidão. Na hipótese de interposição de recurso, antes da remessa ao Egrégio Tribunal, providencie a serventia a expedição de certidão de honorários parciais. Caberá ao advogado interessado providenciar a impressão e entrega na OAB.

Após o trânsito, façam-se os registros necessários e, oportunamente, procedam-se às atualizações, anotações e averbações pertinentes e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Salto, 18 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA